

1500179-35.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... e trazia consigo, para fins de tráfico, 50 porções de cocaína, com peso líquido de 23,08 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, guardas civis estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, onde há grande incidência de tráfico de entorpecentes, momento em que avistaram a acusada parada. Ao se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500179-35.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500179-35.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019723/2022 - 06º D.P. GUARULHOS, 22580889 - 06º D.P. GUARULHOS, 36/22/216 - 06º D.P. GUARULHOS, 2019723 - 06º D.P.

GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAMILA FERNANDA RABANÉA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Camila Fernanda Rabanéa foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 15h15min, na Rua Itaiópolis, nº 18, Vila Rio, nesta cidade e comarca de Guarulhos, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 50 porções de cocaína, com peso líquido de 23,08 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, guardas civis estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, onde há grande incidência de tráfico de entorpecentes, momento em que avistaram a acusada parada. Ao se aproximarem e indagarem sobre sua atitude, de pronto ela afirmou estar na posse de entorpecentes e que estava no local para a mercancia do material que trazia numa pequena bolsa (nécessaire),

assim como a quantia de R\$ 100,00 em notas de R\$ 20,00 e R\$ 10,00. Revistada a bolsa que Camila trazia consigo, localizaram cocaína distribuída em 50 eppendorfs. Interrogada, ela confessou que permanecia no local vendendo entorpecentes. Foi decretada a prisão preventiva da ré (fl. 94).

A acusada apresentou defesa preliminar (fls. 112/127).

A denúncia foi recebida em 06 de junho de 2022 (fls. 131/132).

Não havendo elementos que permitissem absolver sumariamente a ré, iniciou-se a instrução probatória. Em audiência judicial foi ouvida uma testemunha, sendo a ré interrogada ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia. A defesa sustentou nulidade processual por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, assim como a nulidade da prova em razão da atuação indevida de guardas municipais. No mérito, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas três testemunhas.

Anderson Moreira Rocha, guarda civil metropolitano, relatou que, na companhia de seu colega de instituição, fazia patrulhamento pelo local dos fatos, onde sabem ser de grande incidência do tráfico de entorpecentes, e avistaram uma mulher, a qual esboçou atitudes suspeitas. Aproximaram-se e a indagaram sobre sua atitude, e ela de pronto afirmou estar na posse de entorpecentes e que estava no local para a mercancia do material que trazia numa pequena bolsa, assim como a quantia de R\$ 100,00 em notas de R\$ 20,00 e R\$ 10,00. Revistada a bolsa, localizaram substância que aparentava ser cocaína distribuída em 50 epperdorfs. Questionada, a ré alegou que permanece no local para a venda da droga, sendo que Pablo é usuário e estava ali para adquirir o entorpecente, mas ainda não havia vendido para ele. Apenas Camila estava na posse da substância e da quantia, não havendo nenhum indício da participação de Pablo na venda do material (fl. 11).

O guarda civil metropolitano Wagner José Silva apresentou relato idêntico (fl. 12). Pablo Henrique Maia Bispo afirmou que na data dos fatos foi ao local a fim de adquirir cocaína, uma vez que faz uso esporádico. Chegava no local quando os guardas civis realizaram a abordagem na mulher que ali estava, pessoa que não conhece. Não presenciou o momento do encontro da droga. A ré estava com uma bolsa. Não chegou a comprar a droga e não conhece Camila (fl. 13).

Perante o Delegado de Polícia, a ré afirmou que permanecia no local dos fatos vendendo entorpecentes quando os guardas civis chegaram e a surpreenderam. Portava uma bolsa contendo o material que iria vender e o dinheiro do que já havia vendido. Está naquele local há alguns meses e recebe a droga que é deixada num local específico por desconhecido, e após vender entrega o dinheiro no mesmo local, recebendo o valor por seu ato. Não é usuária de drogas e não conhece as pessoas responsáveis pela droga. Não conhece Pablo, o qual estava ali para comprar entorpecentes. Vende cada pino a R\$ 5,00. Ganha R\$ 300,00 por dia quando vende bem. Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi ouvida uma testemunha e interrogada a ré.

Anderson narrou que realizavam patrulhamento pelo local dos fatos com seu colega de instituição, onde há uma quadra poliesportiva. O local é conhecido pela mercancia ilícita de entorpecentes, e sempre passam no local para coibir essa atividade ilícito. Na data dos fatos, passou pelo local e avistou a ré na lateral da quadra, tendo ela demonstrado certo nervosismo. Aproximou-se e questionou a ré sobre o que fazia lá, tendo ela, de pronto, afirmando que levava drogas consigo e que estava no local traficando. Já abordou a ré em outra ocasião. Não se recorda se havia pessoas usando a quadra no local. A ré estava com outro indivíduo, Pablo, e disse que vendia drogas a ele.

Em interrogatório, a ré confessou a prática do crime. Disse que de fato estava no local traficando, tendo sido influenciada por amigos e agido na emoção.

Essas são as provas produzidas.

Rejeito as preliminares arguidas pela defesa.

No entendimento deste magistrado, a prova produzida nestes autos é ilícita. Com efeito, as guardas municipais têm por finalidade a proteção de bens, serviços e instalações do Município. Não lhes cabem as atribuições de polícia ostensiva e preservação da ordem pública (incumbências da Polícia Militar), tampouco as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais (incumbências da Polícia Civil). É o que dispõe o art. 144, §§ 4º, 5º e 8º da Constituição Federal:

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...)

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais (...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (...)

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.”

Na espécie, verifica-se que os guardas civis realizavam ronda quando avistaram a ré com comportamento que classificaram como suspeito e decidiram abordá-la, sendo com ela encontradas as drogas apreendidas.

Os guardas municipais agiram como se policiais militares fossem, excedendo de forma manifesta suas atribuições constitucionais. Não há como autorizar que guardas municipais, fazendo as vezes de policiais militares, realizem patrulhamentos preventivos e a abordagem de pessoas suspeitas.

De se registrar que, como agentes públicos, os integrantes das guardas municipais têm o dever de prender em flagrante qualquer pessoa que esteja cometendo uma infração penal. A toda evidência, seria absurdo impedir que atuassem e obrigar que se permanecessem inertes diante de um crime em andamento. O que não se pode admitir, em hipótese alguma, é que não visualizando situação de flagrância, mas simplesmente suspeitando da ocorrência de um crime, os agentes municipais realizem abordagens, buscas pessoais e diligências investigativas visando à confirmação da suspeita.

No julgamento da apelação nº 1501456-29.2018.26.0567, o Desembargador Sérgio Mazina Martins se debruçou sobre a questão, consignando em seu voto:

“Ora, veja-se então que os guardas civis executaram, desde quando avistaram o acusado – tendo inclusive relatado que “quando este teria demonstrado certo nervosismo. Ao estranharem a situação, tentaram se aproximar do réu, que saiu correndo... ” – autêntica atividade policial de busca e apreensão de mochila supostamente pertencente a Murilo, ou seja, inequívoca investigação de notícia de fato criminoso. Não estavam visualizando, naquele momento, nenhuma situação imediata de flagrância, senão, munidos de uma simples desconfiança acerca do “nervosismo” aparente do acusado passaram pretensiosamente a investigá-la como se policiais fossem. No caso, obviamente, haveriam de ter nada mais que repassado tais informações à Polícia Militar ou à Polícia Civil de Sorocaba – serviços públicos que sabidamente existem naquela cidade, também certamente integrados por agentes policiais da maior competência e gabarito técnico, além do que sob controle e acompanhamento institucional adequado – para que elas, se o caso, encaminhassem as investigações devidas.

Ocorre que guardas civis não são – porque não devem mesmo ser – policiais. Nossa ordem constitucional e legal é claríssima nesse sentido ao dispor que compete às policiais civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, o exercício da atividade de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, assim como compete às polícias militares a atividade de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (Constituição Federal, artigo 144, parágrafos 4º e 5º). Nesse sentido, prossegue o constituinte, às guardas municipais, constituídas pelos Municípios, estão nada mais que simplesmente destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações (Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 8º) (...)

Assim, se um guarda municipal porventura intuitivamente desconfiasse que um

indivíduo estivesse transportando drogas, se esse guarda municipal fosse devidamente treinado, seu procedimento não haveria de ser outro: deveria de imediato comunicar essa notícia à autoridade policial – ou, eventualmente, à Polícia Militar – para que estas, se entendessem ser o caso, procedessem à devida investigação.

(...)

O tema, aqui, não é se o crime existia ou não. Muito menos se era permanente ou não. O tema, no caso, é como esse crime veio à luz. Como ele se tornou público e veio dar nas páginas do processo. O que grita nos autos, portanto, é a ilicitude da prova que o trouxe para nossas mãos” (TJSP; Apelação Criminal 1501456-29.2018.8.26.0567; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019)

A questão também foi analisada com profundidade pelo Desembargador Péricles Piza na apelação criminal nº 1500329-51.2018.8.26.0601. Colhe-se do voto:

“Qualquer do povo pode, de fato, dar voz de prisão a pessoas que estejam a cometer crimes em sua frente. É vedado, no entanto, que os cidadãos investiguem os indivíduos com quem partilham da vida em sociedade, bem como lhes é proibido realizar diligências com o fim de verificar o cometimento de ilícitos criminais. Justamente com o objetivo de retirar dos indivíduos o poder de investigar e punir delitos, impedindo assim que o Direito Penal sucumbisse à mera vingança privada, delegou-se o poder de punir ao Estado. (...)

De tal sorte, a diligência realizada pelos Guardas Civis Municipais, uma vez que invade atribuição constitucionalmente delegada a outros órgãos de segurança pública, representa ampliação indevida de sua esfera de atuação. Tal constitui grave ofensa à regra constitucional, uma vez que, como agente administrativo, regido pela legalidade estrita, falece à Guarda Civil Municipal autorização para investigar possíveis ilícitos penais.” (TJSP; Apelação Criminal 0007763-32.2008.8.26.0597; Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro: 03/12/2019)

Nada obstante, a Corte de Justiça local, de forma quase unânime, não vê ilegalidade em abordagens como a realizada no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça também tem decidido que “a busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator” (AgRg no AREsp 1565524/MS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019).

Diante disto, a fim de prestigiar a segurança jurídica, curvo-me a este entendimento e deixo de reconhecer a ilicitude da prova.

Não houve ofensa ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal, pois acusação e defesa formularam perguntas diretamente à testemunha.

No mérito, não obstante a manifestação da combativa defesa, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/07), laudo pericial de objeto (fls. 135/137), laudo de constatação prévia (fls. 16/18) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 138/140), os quais constatarem no material apreendido a presença de cocaína, substância previstas na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre a acusada.

A ré confessou a prática do crime e sua confissão se harmoniza com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e provas colhidas em juízo.

Com efeito, o guarda municipal Anderson relatou que fazia patrulhamento pelo local dos fatos, abordou a ré em razão do comportamento suspeito que apresentava e encontrou em poder dela, no interior de uma bolsa, as drogas apreendidas.

Para além da confissão espontânea, a quantidade de entorpecentes (50 porções de

drogas), o dinheiro apreendido (R\$ 100,00 em notas trocadas) e o contexto no qual desenvolvida a ação criminosa (abordagem em ponto de venda de drogas) não deixam dúvidas de que as drogas se destinavam ao tráfico.

Provado, assim, que a ré praticou o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo são favoráveis à ré. Ela não registra maus antecedentes (fls. 22/23). Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se apenas da reprovabilidade insita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Por fim, tratando-se de crime contra a saúde pública, não há comportamento vitimológico a ser analisado.

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 não são inteiramente favoráveis à acusada.

Ela foi surpreendida com 23 gramas de entorpecente, quantidade que não se revela elevada o bastante para justificar maior censura da sua conduta, visto não destoar da quantia comumente apreendida em situações semelhantes. Não há variedade de drogas, uma vez que a ré foi surpreendida com apenas um tipo de estupefaciente. A droga apreendida é de alto potencial nocivo. A natureza do entorpecente, contudo, será valorada na terceira etapa da dosimetria. Utilizá-la neste momento atentaria contra o princípio do *ne bis in idem*.

Destarte, inexistindo circunstâncias desfavoráveis a serem valoradas nesta fase, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes. Presentes as atenuantes do art. 65, I, e III, d, do Código Penal, pois a ré tinha apenas 18 (dezoito) anos na data do crime e confessou espontaneamente a prática do crime, mas sem reflexos na pena (Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Não se configurou nenhuma causa de aumento de pena. Possível, por outro lado, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, a acusada é primária e ostenta bons antecedentes criminais. Nada há nos autos que possa indicar que ela se dedique a atividades criminosas ou que integre organização desta natureza. Ela preenche, deste modo, todos os requisitos exigidos pelo citado dispositivo legal.

A ré responde a processo criminal em razão da prática do mesmo crime. Tal processo, contudo, não pode impedir a incidência do redutor, pois diz respeito a fato posterior ao apurado nestes autos e ainda está em andamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que de que “[a] negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06” (AgRg no AREsp 1899869/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Assim, de rigor a aplicação da minorante estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Não é possível, contudo, a aplicação do redutor em seu grau máximo. A acusada tinha em seu poder cocaína, droga de alto poder viciante e elevada nocividade à saúde. Nesse passo, ante a natureza do entorpecente, reduzo a pena em 3/5 (três quintos), fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, sanção que torno definitiva.

A acusada não goza de padrão de vida elevado. Por este motivo, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Em razão da primariedade e quantidade de pena aplicada, a ré poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo tempo da pena, e multa, que fixo em 10 (dez) diárias, no piso legal.

Isto posto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar a ré Camila Fernanda Rabanéa, por violação ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no piso legal. A reprimenda corporal fica substituída por pena restritiva de direito e multa, na forma acima estabelecida.

Expeça-se alvará de soltura.

Com fulcro no art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do valor monetário apreendido em favor do FUNAD.

Condeno a acusada ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, por ser economicamente hipossuficiente, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Guarulhos, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA